壹、定义 (§1072) ⇒ 父母本位(舊法) ⟶ 養子女本位

↳ 收養為孫子女 ⟨ 肯定說(史、戴炎輝、趙)
否定說(胡、曹、棋、戴、林)

貳、實質要件

一、收養合意 (認定時點:契約訂立時)(SC 104台簡抗1裁)

1、僅有養育事實 無成立親子關係之意時 非收養 (SC 23上4823例),通謀虛偽亦無效 (J91:收養子女係為其與婚生子女結婚者,仍可結婚,非收養)

2、收養契約屬身分契約

(1) 不得代為收養 (SC 26上486例、33上641例、33上5102例)

(2) 不得遺囑委託他人死後代為收養 (SC 32永上284例)

(3) 配偶仍得自行收養 (22院907)

3、法代同意 (身分行為不得代理之例外規定)

(1) §1076-2Ⅱ:7歲以上應得法代同意

(2) §1076-2Ⅰ:<7歲 法代代受並代為意思表示

(3) 無法代則應先訂監護人

4、受監護之人於正常狀態中收養或被收養

(1) 肯定說-須法代同意說 (戴)

(2) 肯定說-無須法代同意說 (棋)

(3) 肯定說-未滿18歲須法代同意說 (史、振)

(4) 否定說:違背養子女利益,法院應不予認可 (戴東雄)

(5) 實體審酌說:無否認收養能力之必要 ⇒ 為保護子女利益 法院應具體審酌 (林) { 收養成年人 ✓
受監護宣告之人有配偶得共同收養 ✓
無配偶:有違 BIOC ✗

二、一定年齡差距 (JP:長1天以上即可)

1、~96 §1073:相差20歲 ⇒ 夫妻共同收養或收養他方子女亦受限制 ⇒ 對子女不利

2、J502:§1073 符合倫常,合憲,但於前情形應設有彈性規定

3、96~ §1073Ⅰ:20歲↑ / Ⅰ但:共同收養一方20歲↑,他方16歲↑ / Ⅱ:收養他方子女,16歲↑

三、非近親 (§1073-1)

⓪ 舊法無明文 ⇒ SC 49台上1927例 類推§983近親結婚 ⇒ 74~明文

① 直系血親

1、生母收養自己之非婚生子女

(1) 肯定說(史、棋):俾非婚生污名,保全名譽,收養適為有利

(2) 否定說(胡、林):準正條件已足,§1072明文應收養他人子女,且有§1065Ⅱ,不待認領即生直系血親關係

2、經準正或經生父認領 ⇒ 不得收養

3、未受认领或準正之非婚生子女生父收养

(1)肯定说（史、楨、林）：以收养蔽社会耳目⇒不妨許其收养⇒縱认无效，亦有§112轉換為有效之认領⇒实質上兩说將致相似結果（司法院81.2.27（八一）廳民一02696号函研究意見）

(2)否定说（胡、戴）：与法條文义違背（§1072）（通）

② 直系姻親，但夫妻收养他方子女不在此限

↳不收养他方子女而欲收养他方子女之配偶：文义解释✗⇒目的性擴張 但 使合立法意旨

↳不得再收养他方子女⇒使夫妻成為手足 不合立法意旨

③ 旁系血6親等內、旁系姻5親等內，輩分不相当⇒指差一輩⇒兄姐不得收养弟妹、叔公不得收养侄孫

四、夫妻共同收养（§1074本文）

① 夫妻一方收养他方子女⇒有§1073-1① 故僅一方即可

② 一方不能為意思表示或生死不明逾3年

③ 性質

1、個別收养说（通、楨、史林）：不因夫妻離婚受影响，各別成立收养契約

2、一體收养说（少、史）：僅成立1契約⇒任何一方有无效或得撤銷原因時亦得對他方主張

④ 事实上夫妻不得類推§1074（SC 105台簡抗11裁）

⑤ 同性伴侶不得類推§1074（SC 106台簡抗129裁、107台簡抗97裁）

⑥ 一方終止不及於他方之收养（SC 85台上298）

五、一人不得同時為2人之养子女（§1075）⇒僅許為一對夫妻或一人收养（35院解3120）

↳離婚不影响收养，养父母与他人再婚後其後夫/妻依本條不得再收养（§1076本文）

六、夫妻一方受收养應得他方同意（§1076本文）

1、夫妻一方受收养而有共同生活事实按§1114②他方配偶對收养人有扶养义務

2、但：他方不能為意思表示或生死不明逾3年不在此限

3、一方被收养⇒配偶、收养人成立直系姻親，不得收养（§1073-1②）

4、夫妻共同被收养

(1)否定说：夫妻為手足⇒禁婚親（曹、胡、戴、林）

(2)肯定说：可保和平、傳承香火⇒婚养子合法（鼎、趙、楨）

七、子女受收养應得父母同意（§1076-1 I 本文）

1、与法代同意出养权不同，應指本生父母之固有同意权（非親权）

2、子女不限未成年，且但②之事实上不能為意思表示應指父母不詳、死亡、失蹤、无同意能力，非停止親权等法律上不能之情形

3、II：同意應作成書面並公証，得以言詞向法院表示並記明筆錄代之；III：同意权之行使不得附條件或期限⇒身分行為之安定性

4、若父母＝法代⇒§1076-2 III 不必再行使§1076-1同意权

參、形式要件

一、作成書面（§1079Ⅰ）

二、向法院声请认可（§1079Ⅰ）（性質：非訟事件之裁定）

1、审酌标準（§1079-1）：BIOC（似与§1083-1 $\xrightarrow{準用}$ §1055-1重複）⇒應係指導條款

(1) 近親（旁血6、旁姻5、輩份相当）、繼親（夫妻一方收養他方子女）收養外，应委託收出養媒合服務者代覓收養人（兒少§16Ⅰ）

(2) 訪視調查，完成評估報告（兒少§16Ⅱ）

(3) 評估報告係审酌之必要文件（兒少§17Ⅰ、家事§115Ⅲ⑤）

(4) 得為試行收養（兒少§17Ⅱ②、家事§116），嗣後法院认可溯及开始共同生活时發生效力（兒少§19Ⅰ後）

2、不予认可之情形（§1079-2、1079Ⅱ）

(1) 收養有无效、得撤銷原因或違反其他法律（§1079Ⅱ）

(2) J712：舊兩岸人民§65① 違反憲§22收養自由、§23比例原則 失其效力

(3) 成年收養有脫法行為（§1079-2）

① 意图以收養免除法定义務：免除对本生父母之扶養义務致其生活困難

② 足认收養对本生父母不利：雖本生父母足夠財產維持生活，但有孤苦无依、殘障、長期臥病等情事

③ 其他重大事由足认違反收養目的 <
ex：逃漏國家稅賦（戴）
林：上例為无收養合意，自屬无效，本款所謂之收養目的為何不得而知

三、舊法：~74 ⇒ 应以書面為之，但自幼扶養子女者，不在此限（SC108台上大1719裁）

1、但僅為方式之例外，仍須本生父母同意

2、未成年若有法代且該法代事实上得為意思表示者，应有§1076-2之方式始成立收養关係

肆、无效（§1079-4 準用）

一、§1073 未達法定年齡之間隔：74修正前非当然无效，僅得撤銷（SC 32上886例、J87、35院解3120）

二、§1073-1 近親及輩分不相当：74修正前认違反公序良俗无效（通、SC49台上1927例）

三、§1075 一人同時為二人之養子女

1、74修正前认无效（通）

2、同時受非夫妻兩人收養（ex：法院誤為夫妻而认可）⇒兩关係均為无效

3、先後被收養 ⇒ 後收養无效，前收養有效

四、§1076-1 缺乏父母同意、同意未作成書面、未公証 或 同意附條件或期限

五、§1076-2Ⅰ 未滿7歲未由法代代為及代受意思表示

六、§1079Ⅰ 缺乏書面或法院认可：74修正前 SC29上1817例 认§73无效

七、不限此條：欠缺收養意思、附條件或期限之收養、代理他

八、收養认可非效力規定 ⇒ 不應予以认可而认可，效力仍依民法判斷（ex：§1079Ⅱ若得撤銷但认可⇒仍為得撤銷，否則§1079-5淪為具文）

九、无效之主張

1、不待判決当然自始无效，若有爭執自得提起收養关係不存在之訴(家事§3Ⅰ甲類事件)

2、收養关係不存在之訴屬確认之訴⇒无形成效力，有利害关係之人均得提起

3、有无效原因而法院未經查明予以认可

(1)无效说：縱經认可，仍違強制規定无效，裁定可抗告(家事§92Ⅰ)，无收養无效之訴，既稱確认自无法解釋成有形成力(楊与齡、林)

IF 廢止无效⇒同for舊裁判无效、新訴訟撤銷

(2)有效说：於確认无效之訴或职权撤銷前，因法院认可有公信力，應认裁判无效⇒經法院裁定无效後始溯及收養行為时无效(戴)

4、被告適格(家事§39Ⅰ、Ⅱ)：当事人一方起訴⇒他方被告／第三人起訴者⇒双方当事人被告

5、SC 96第1次民庭決议(SC 104第4次民庭決议廢止)：養父母已死亡不得再以養子女為被告起訴 ↔ 通：得僅以未死亡一方為被告

伍、撤銷(§1079-5)

一、~74：違反§1074、1076(30院2271、SC 31上2093例)

二、§1074夫妻一方单独收養(§1079-5Ⅰ前)

1、限一方单独声請法院认可而被认可⇒一方冒用他方名义声請法院认可而被认可？

(1)嚴格解釋说(否定)

(2)寬鬆解釋说(肯定)

A、楳：撤銷权人不行使时可认默认共同收養，撤銷时双方之收養均被撤銷

B、林：身分行為本即无法代他人為之，故被冒用方自无收養，並得以§1079-5Ⅰ行使撤銷权

2、时效：6月/1年(§1079-5Ⅰ但)⇒除斥期間⇒經过後即可单独收養

三、§1076夫妻一方被收養时未得他方同意(§1079-5Ⅱ本文)：被詐欺者，應先§92、93撤銷同意再§1079-5Ⅱ撤銷收養

四、§1076-2七岁↑被收養时未得其法代同意

五、方式

1、撤銷收養之訴(家事§69)⇒以訴為之

2、被告適格同无效(家事§39)

六、效力：不溯及既往、一方陷於生活困難得請求相当金額、回復本姓及与原親屬間权利义務，第三人已取得之权利不受影响(ex：繼承权)(§1079-5Ⅲ $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1082、1083終止)

陸、效力

一、發生时点

1、舊法：~96未明文；現法：96~§1079-3溯及收養契約成立时

2、兒少§19Ⅰ前、中、後：成立書面契約；无契約以向法院声請时；試行收養以开始共同生活时(兒少§17Ⅱ)

3、兒少§19Ⅱ：收養人於声請认可後、裁定前死亡⇒若对養子女有利，仍可為认可裁定⇒仍有§1079-3但適用

4、林：有可能使子女皆无法取得双方財產，且§1087之責任有爭议

二、親屬关係發生(§1077)

1、養父母及子女皆同婚生子女(§1077Ⅰ)

2、与本生父母之天然血親关係仍存在 (J28)

3、法律另有規定⇒§1078 維持原姓氏 (§1078Ⅲ $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1059Ⅱ~Ⅴ)

4、收養成立⇒發生直系血親关係⇒互負扶養义務(§1114①)、互有繼承权存在(§1138①、②)，子女未成年由養父母行使親权 (sc 20上2305例)

5、養祖孫关係

(1) 養子女於收養认可時已有直血卑者，收養效力僅及於未成年之直血卑 (§1077Ⅳ本文)

(2) 已成年之直血卑欲發生祖孫关係應表示同意 (§1077Ⅳ但)⇒同意應書面同意經公証並不得附條件或期限 (§1077Ⅴ $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1076-1、1076-2)

三、与本生父母及其親屬間权利关係

1、於收養关係中停止之 (§1077Ⅱ本文)；繼親收養不受影响(§1077Ⅱ但)

2、收養後，收養者与養子女之本生父母結婚時，回復与本生父或母及其親屬間之权利义務，但第三人已取得权利不受影响(§1077Ⅲ)

3、回復无溯及效力，§1077Ⅲ但 僅止於注意規定

柒、終止

一、合意終止 (§1080)

1、实質要件

(1) 双方終止收養合意

A、身分契約⇒須以当事人有終止收養之合致⇒通謀虛偽之終止无效

B、~96：同意→96~：合意

(2) §1080Ⅴ、Ⅵ：養父母双方代理(§106)⇒例外規定應得終止後$\underbrace{\text{為其法代之人同意}}_{\text{Ⅵ：7岁↑}}$或$\underbrace{\text{由其代為之}}_{\text{Ⅴ：7岁↓}}$

A、本生父母仍生存：本生父母 / 一方死亡：生存之他方 / 均死亡：終止後監護人

B、養父母已離婚：与非行使权利一方⇒他方為法代可同意 / 与行使权利义務一方解除⇒他方代為同意

C、養父母於收養後之一方死亡⇒終止後仍与死亡方有收養关係⇒开始監護⇒終止後監護人

(3) §1080Ⅵ⇒轉收養契約於法不合(自己代理)

(4) 夫妻原則共同終止 (§1080Ⅶ)(通)：單独終止時效力不及他方 (§1080Ⅷ)

A. 未終止之一方不能為意思表示或生死不明逾三年⇒开始監護 (§1091)

B. §1081Ⅰ④：与不能為意思表示或生死不明逾三年之養父母終止 (其他重大事由)

C、§1080-1Ⅰ：与死亡之一方終止

D. 限共同收養時有其適用 (單独收養无須他方配偶同意)

↳ ex：收養時无配偶而後結婚、違反 §1074 未撤銷、未得他方配偶同意而未經撤銷

2、形式要件 (§1080Ⅱ)

(1) 書面為之(§1080Ⅱ前)⇒户籍§8Ⅱ 雖規定須登记，惟此屬報告之登记，非要件

(2) 養子女未成年應向法院声請认可 (96~§1080Ⅱ後)

二、宣告終止（裁判終止）

1、声请人：< 养子女＋兒少福利主管机关＋本生父母 / 养父母＋老人福利机关 （96~§1081（参考兒少§70））

2、诉种：非讼事件（SC 110台簡抗大33裁）

(1) 未成年：非讼（无争议）（§1081Ⅲ＋家事§3Ⅴ⑬、74）

(2) 成年

A、非訟說（家事§3⑬、家事審細§108④）（実通：SC 101台抗962、102台簡抗45、577、103台簡抗165、104台簡抗152、210、105台簡抗70、204、106台簡抗136、157、107台簡抗11、66、115、108台簡抗208裁）

B、訴訟說（家事§3Ⅲ④、45、46、47、69Ⅲ、舊民訴§583）（SC 109台簡抗262裁）

3、原因（§1081Ⅰ）

① 对他方虐待或重大侮辱 → 虐待：身体上、精神上受不堪痛苦之積極或消極行為；侮辱：毀損名譽之行為 但限情節重大（林、鼎）

↳ ex：无故將养母鎖在門内1日（SC 29渝上2027例）、肆意辱罵（SC 50台上88例）、逼養女為娼（SC 20上2020例、通）

② 遺棄他方：謂指扶养义務不履行（与§1052Ⅰ⑤不同）（SC 33上5296例）

↳ SC 41台上744例：離婚約定一方行使負担权利义務時，不得以棄置為由請求另一方終止

③ 故意2年↑未緩刑宣告：舊法~96 → 限养父母提起

④ 其他重大事由：重大須以社会通念及当事人背景具体判斷之

(1) 侮辱他方（SC 28渝上843例、33上3997例）、吸食毒品（SC 31上1369例）、誘使養子女暗操淫业（SC 48台上1669例）

(2) SC 57台上359例：行使親权並經证明无效果前，難认不服監护已成之重大事由

(3) 浪費財產、生死不明逾3年（~96 ④.⑤ / 96~④）

(4) 审酌原則：未成年人应以 BIOC（§1081Ⅱ、1083-1）

三、死後終止（§1080-1）

1、沿革：J58：類推§1081⑥重大事由 / 74~96 §1080Ⅴ：养子女无謀生能力 / 96~§1080-1Ⅰ 法院許可

2、要件

(1) 养父母死亡

A、父母俱亡亡說（樹）

B、單方死亡說（林、SC 79.5.29民庭決议、JP通）：§1080-1Ⅰ 参考JP§811Ⅵ，一方死亡应由他方以法代身分代為声请或养子女自行声请

(2) 声请法院許可：§1080-1Ⅱ：7歲↓以終止後之法代向法院声請 / §1080-1Ⅲ：未成年 应得終止後之法代同意

(3) §1080-1Ⅳ：未顯失公平（ex：榮民收养成年子女案）

(4) 非訟事件（家事§3Ⅳ⑦ 丁類非訟）

四、終止收养之无效（§1080-2）：違反§1080Ⅱ 以書面為之、Ⅴ<7歲未由終止後法代声請、§1080-1Ⅱ 养子女未成年未經法院认可終止

五、終止之撤銷（§1080-3）：違反§1080Ⅶ、1080-1Ⅲ 7歲↑未得終止後法代同意、Ⅲ未共同終止（除斥期間：6月/1年）

六、終止生效時點：
- 合意：裁定確定（未成年）/ 合意作成書面時（成年）
- 死後、宣告：裁判確定

七、效力

1、对養方效力

(1) 身分上效力 (§1083)

A、权利义務均消滅

B、養子女於收養期間所生之子女，與養方之关係隨終止而消滅 (戴、林、鼎、SC33上5318例)

↳ 史、棋、34院解3010 法務部103法律10303508150 認若養子女之子女有意思能力，經同意願留養家例外不消滅 ⇒ 96修正§1083應无法再相同解釋院解3010應停止適用 (林)

(2) 財產上效力 (§1082)

A、舊法：經判決＋无過失

B、因終止生活困難得請求相當金額，請求顯失公平得減免之 (ex：有虐待情事可认对養父母而言顯失公平)

C、SC33上6097例：養子女終止未成年時由本生父母負扶養义務 ⇒ 非因終止困難之情形

2、对本生方效力 (§1083)

(1) 養子女及收養效力所及之直血卑與本生父母及其親屬間权利义務應予回復，若收養時仍維持本姓，无回復必要

(2) J28：收養不影响子女與其本生父母及親屬关係 ⇒ 回復係权利义務

(3) §1083但 第三人权利不受影响

A、養父母已对養子女之結婚已為同意，本生父母不得再主張未經同意而撤銷 (史、棋)

B、已繼承遺產，不因終止受影响 (史、棋)

C、戴：民法僅欲解決而置規定 ⇒ 係注意規定，因本生不溯及既往即无影响第三人权利可能

捌、死亡消滅

一、黃待淳：親子关係不消滅

二、林、戴：身分关係消滅 (§6：人之权力始於出生終於死亡)，但收養契約仍存在

三、胡：死亡不因死亡消滅且因死亡發生特殊作用 (祭祀、有後、血統連續之擬制)

四、史：養子女死亡解消，但養父母死亡不完全解消 (養父母死亡仍稱養父母之姓，亦不得再被他人收養)